

論「以股權淨值做為交換損失的時價」之不當：

最高行政法院 107 年判字第 48 號判決評釋

作者：張海倫¹

授課老師：柯格鐘 教授

內容

第一章	前言	2
第二章	事實	4
第三章	爭點	5
第四章	有無稅上「損失」的發生	6
第一節	民商法的形式	6
第二節	財務會計的處理	7
第三節	所得稅法中的定性	10
第一項	損失的定義	10
第二項	「財產交易」、「損失」、「財產交易損失」	10
第五章	關於要件「時價」	12
第一節	時價的意義應接近第 100 條第 1 款的售價	12
第二節	股權淨值是時價的替代而非內涵	14
第六章	稅上「損失」已否實現？	16
第七章	損失金額的證明	17
第一節	關於待證事實	17
第二節	關於舉證責任的分配	17
第三節	關於「證明度」與「精確度」	18
第八章	結論	22
第九章	參考文獻及裁判書簡稱	23
附錄一：查準 100 的結構		24
第一節	查準 100 I	24
第二節	查準 100 II	24
第三節	行為時查準 100 III（現為 IV）	24
附錄二：A 公司個體年報揭露之「VIEWSONIC CORPORATION」持股		25
附錄三：關係圖、時間軸及各種金額		26
附錄四：與本件交易類似的商法規定情境		27

¹ 作者現就讀於台灣大學科際整合法律學研究所三年級，學號為 R12A41005。

第一章 前言

原告（同本件上訴人）瑞軒科技股份有限公司（下稱「A 公司」）於民國 101 年度營利事業所得稅結算申報時，列報包含投資損失新臺幣 287,317,251 元等項目遭被告（同本件被上訴人）北區國稅局（下稱「稅局」）調整。A 公司就投資損失核定為 0 元部分不服，經稅局及財政部先後做出不利 A 公司之復查及訴願²決定後，提起本件行政訴訟。臺北高等行政法院（下稱「北高行」³）對於 A 公司所做的敗訴判決，經本文所評釋之最高行政法院（下稱「最高行」）⁴判決廢棄發回後，兩造於北高行⁵達成和解確定。若依本件出現的法律主張依時序排列，首先，A 公司當時已是我國上市公司⁶，營所稅申報強制⁷由會計師查核簽證，一開始卻「勇於」挑戰稽徵與稽徵實務對於查準 99「投資損失」需被投資公司有虧損且有該條第 2 款四種公司法事件態樣的見解⁸，列報⁹高額「投資損失」，果遭稅局

² 參見財政部中華民國 104 年 11 月 18 日發文字號台財訴字第 10413957860 號（案號：第 10400729 號）訴願決定。

³ 臺北高等行政法院 105 年度訴字第 97 號判決

<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPBA,105%2c%e8%a8%b4%2c97%2c20161109%2c2>

⁴ 最高行政法院 107 年度判字第 48 號判決

<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPAA,107%2c%e5%88%a4%2c48%2c20180123%2c1>

⁵ 臺北高等行政法院 107 年度 訴更一 字第 15 號判決

⁶ A 公司於 90 年度由上櫃公司（股票代碼 5405）轉為上市公司（股票代碼 248）。

⁷ 營利事業委託會計師查核簽證申報所得稅辦法第 3 條第 2 款「（下列各營利事業，其營利事業所得稅結算申報，應委託經財政部核准登記為稅務代理人之會計師查核簽證申報：）二、公開發行股票之營利事業」。

⁸ 【福興案（93 年度營所稅）（高高行）】被告主張「按財政部 98 年 9 月 14 日發布修正查核準則第 99 條第 2 款「投資損失應有被投資事業之減資彌補虧損、合併、破產或清算證明文件。」及增訂第 4 款「因被投資事業合併而發生投資損失，以合併基準日為準。」其並非稅捐稽徵法第 1 條之 1 所指解釋函令。且依查核準則第 116 條規定，原告行為時之法令規定尚無明定「合併」產生之投資損失可自當年度營利事業收入總額中減除，自不宜擴張解釋其可以適用」。

⁹ 最高行政法院 103 年度判字第 538 號判決

<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPAA,103%2c%e5%88%a4%2c538%2c20141002%2c1> 最高行認為「稅捐之課徵，納稅義務人有協力之義務，納稅義務人將社會生活事實所衍生之利益類型化，透過稅捐申報之方式，說明其**法律關係**而由稅捐機關審查之。」自行申報就是納稅人初步的法律主張，而且不用提供證物。

核定時全數剔除¹⁰。在復查¹¹、訴願¹²、事實審¹³、法律審¹⁴的救濟過程中，又就同一事實，審查了行為時查準 100 共三款，筆者認為本件很適合用來探討營利事業所得稅查核準則（下稱「查準」）第 99¹⁵條與第 100¹⁶條，及行為時第 100 條各款之間的關係。

¹⁰ 理由係「B 公司並無減資彌補虧損、合併、破產或清算之情形，且（A 公司）提示之鑑價報告無法證明股權轉換基準日之股票時價」，筆者不確定為何查準 99 條涉及「時價」的證明。

¹¹ 於復查階段，A 公司對於查準 99 並未多加爭執，而是轉而追加主張查準第 100 條第 3 款。據筆者觀察，A 公司似乎不想提 B 公司的淨值，或許是因為對於 B 公司虧損（參見註 49）一事特別敏感，而是談 C 公司的淨值。復查理由則提出實質課稅、租稅規避的概念，並認為本件涉及無實質的組織調整，且「A 公司提供的鑑價報告不足證明損失的客觀性與準確性」，可謂捨某些損失計算中的「時價」證明問題，而改為否認「損失」（參見註 47）本身。

¹² 基於稅局對其租稅規避的懷疑，A 公司於訴願階段主張應適用所得稅法第 43 條之 1。財政部認為因無查準 99 條 2 款四種態樣，故稅局不予適用查準 99 條屬合法；在查準 100 當時共三款的範圍內，關於第 1 款「買賣」，訴願決定理由（四）提到 A 公司「主張應比照最高行政法院 92 年度判字第 1099 號等 3 判決，對財產交易所得之認定原則（即以股權轉換日被投資公司之股權淨值為出售價格），核定本件財產交易損失乙節」，財政部認為「上揭最高行政法院等 3 判決，係出售股權及股票作價抵繳股款」，其中「出售股權」即第 1 款，「股票作價抵繳股款」即行為時第 3 款；並稱「與本件股票交換之情形明顯不同，且股票交換之損益應依查核準則第 100 條第 2 項規定，其時價無法可靠衡量時，...，自應依換出資產之帳面價值（即投資成本）作為換入資產成本入帳，並無已實現之損益」，亦即無論「換出資產」之時價能否可靠衡量，凡股票交換均適用查準 100 條 2 款做為「實現」的依據。稅局在於原審沿用財政部之此部分見解。至於第 100 條第 3 款，財政部認為不適用的理由是「該鑑價報告無法證明股權轉換基準日股票之公平價值，換股比例是否合理暨該資產所抵充出資股款之金額低於成本之客觀性及準確性亦無從衡量」，惟筆者對於在本件要求人民證明「合理（參見註 49）」持保留態度，因 A 公司與 B 公司在本件事實前後均非屬關係人，此由同一訴願理由中，財政部關於 A 公司「對 B 公司僅持有 1% 股權，尚非具有從屬關係，自無所得稅法第 43 條之 1 規定之適用」可知。

¹³ 直到最高行之前，似乎沒人考慮第 2 款（交換損失）第 1 句，而直接跳到同款第 2 句「時價」無法可靠衡量的情境，進而爭執 A 公司應否以原對 B 公司的持股之帳面價值，將 C 公司股票入帳（carryover basis）。

¹⁴ 北高行認同 A 公司在訴願階段關於適用行為時查準 100 條第 3 款（現為 IV）的法律主張，但以 A 公司在行政救濟階段未盡主觀舉證責任為由，認為「核定/復查/訴願」行政處分「合法」，最高行認為依 A 公司在原審提出卻被無視的新事證應已足夠適用查準 100 條第 2 款第 1 句。

¹⁵ 本件非因 A 公司持股比例微小或非採權益法而排除查準 99 條之適用。

¹⁶ 查準 100 條可能較適用於非金融資產，參見註 35。

第二章 事實

- 1 A 公司於 89 年 9 月以 10,000,000 美元（折合臺幣約 312,800,000 元¹⁷）投資 Viewsonic Corporation（US）（下稱「B 公司」）普通股 5,000,000 股。
- 2 B 公司所屬集團於 100 年 8 月 10 日在英屬開曼群島設立 Viewsonic Corporation（Cayman）公司（下稱「C 公司」）作為 B 公司之控股公司。C 公司設立日股權淨值¹⁸（股本＋資本公積）1,863,900,000 元，C 公司發行股數 73,143,600 股（即普通股股本 731,436,000 元/面額 10 元），C 公司設立日每股淨值為 25.482749。
- 3 A 公司與 B 公司於 100 年 11 月 22 日簽訂股份轉換協議書，約定由 B 公司將 A 公司原本持有 B 公司普通股 5,000,000 股轉換為 C 公司普通股 1,000,000 股。
- 4 A 公司於原審起訴狀證物提示 C 公司合併股東權益變動表載有 100 年 12 月 31 日股權淨值金額 1,933,963,000¹⁹元（=1,956,647,000 元-少數股權 22,684,000 元）。
- 5 A 公司於 101 年 1 月 17 日「實際交換取得」²⁰C 公司股票。
- 6 A 公司就 C 公司之普通股股票 102 年 3 月 31 日價值提出鑑價報告²¹。

¹⁷ 此金額可勾稽到 A 公司最早期（90 年）的公開財報，與本件所考量的幾個時間點的帳面價值所有差距的主要因為是從 90 年到本件事實相關日期之前，A 公司曾多次對此持股提列財務會計上的減損（參見註 20、「附錄二：A 公司個體年報揭露之「VIEWSONIC CORPORATION」持股」）。據筆者查詢，在本件之前，A 公司似未曾針對股權投資的營所稅爭議提起行政訴訟。

¹⁸ 「淨值（net value）」比較是財務金融領域的用詞，IFRS 中譯幾乎無使用此詞。至於「淨資產（net asset）」，概念框架第 8.1 段「大多數個體編製財務報表時係採取財務資本觀念。於財務資本（如投資之貨幣或投資之購買力）觀念下，資本與個體之淨資產或權益同義。於實物資本（如營運能力）觀念下，資本被視為以每日產出單位為基礎之個體生產能力」。

¹⁹ A 公司稱該金額「僅與 100 年 8 月 10 日淨值 1,863,900,000 元差異 70,063,000 元，尚不及 4%」，似意在佐證在列報金額自始有據。

²⁰ 【寶虹換翔名案／溫達俊（綜所稅）（最高行）】最高行稱「上訴人於股份轉換基準日...既已依企業併購法第 29 條規定之股份轉換方式以股換股，取得翔名公司之股權，即取得翔名公司股東之地位，而得行使股東之權利，包括出席股東會參與表決等共益權，及請求盈餘分派等自益權，其換股之權益已經實現，自應以股份轉換基準日...為計算換股結果有無增益之時點。...翔名公司是否交付股票完成新股變更登記，僅為對抗要件，並非股份權利取得之生效要件」。

²¹ 據筆者推測，之所以 A 公司提出這個時間點的鑑價報告，是因為該公司從 102 年第一季開始編製 IFRS 財報之故，參見註 102。

第三章 爭點

在查準 99 條採「憑證定義說」²²搭配「第 2 款四種態樣列舉說」²³的前提而排除本件適用查準 99 的可能性之後，能否適用做為查準 99 條備位規定的查準 100 條，則需判斷：

- 一、關於稅上損失的有無²⁴，A 公司依照民商法律關係「換得」資產是否具有同一性或延續性，又判斷標準為何？
- 二、若不具同一性或延續性，則換入資產的「時價」能否可靠衡量，又「時價」意義為何？
- 三、若不能，則營所稅上是否要讓損益實現，又鑑於我國對於利益(=所得)的規範較多，則可否對稱適用於損失？
- 四、若可，則 A 公司對於稅局應負的協力義務(對法院的舉證²⁵責任在稅局身上)，與「以行政處分合法性(而非損失「真實」)乃本件訴訟標的」為前提，身為原告的 A 公司應在事實審法院配合法院依職權調查證據的協力義務應有多高？

²² 民法債編的「各種之債」常被稱為「有名契約」或「典型契約」，相關條文規定了一些常見契約關係所生法律效果的構成要件，對於舉證責任的分配是間接的，筆者提出的「有名扣除額」概念則係以憑證定義扣除額，而「憑證」即使並非直接等於「證據」也至少可說是關係密切，涉及查準 99 的稅務訴訟中往往是以納稅人未能「證明其有投資損失」作為判決納稅人敗訴的理由。

²³ 關於查準第 99 條第 1 句提到「投資損失應有被投資事業之減資彌補虧損、合併、破產或清算證明文件」，筆者認為查準 99 條 2 款四種公司法事件的態樣彼此之間的關係，提出金額憑證定義列舉說。詳言之，「金額憑證」是因為比照同查準其他扣除額條文體例，呼應柯老師說納保法第 7 條第 2 項是核實課稅原則所核對的是「憑證」，而非類似民事損害賠償的雙重因果關係(先有被投資公司的公司法事件，再證明因投資公司因該公司法事件蒙受多少「損失」)。「定義」是因為查準 99 條並無會計基礎，所以是稅上的發明，本文對於查準 99 條這種扣除額的稅法上正當性薄弱，所以適用上應限縮，要件具備後才有這種損失的「發生」，以免實務往往為否准查準 99 扣除額透過個案中操作查準 63 提到的「實現」來限縮，反而破壞「實現」標準的穩定性。「列舉」是因為查準 99 為一種有名扣除額。

²⁴ 「發生」為 A 公司的措辭，筆者理解為等同「有無(所得、損益)」；「產生」是稅局的措辭，參見註 47。

²⁵ 納稅者權利保護法第 7 條第 4 項及舊稅捐稽徵法第 12 條之 1 均規定第 4 項均規定「前項租稅規避及第二項課徵租稅構成要件事實之認定，稅捐稽徵機關就其事實有舉證之責任」，參見註 75。

第四章 有無稅上「損失」的發生

第一節 民商法的形式

本件的基礎法律關係是 A 公司與 B 公司之間的契約關係，由於非屬關係人或集團²⁶內交易，所以無論「B 公司所屬集團」的目的為何，A 公司都只是 B 公司（所屬集團²⁷）庫藏股交易²⁸的相對人而已。互易契約做為我國民法第 398、399 條規範的一種債編有名契約，基本上都準用買賣契約²⁹，或者只是幾個以買賣做為基礎型交易的結合³⁰。至少如最高行所說，「(A 公司) 與 (B 公司集團) 於 100 年 11 月 22 日簽訂股份轉換協議書，已在 (C 公司) 設立逾 3 個月以後，上訴人顯非於 (C 公司) 成立時，以其持有 (B 公司) 股票作價抵充出資股款，應係股權資產之交換」。由於跟公司法上的股份交換與股份轉換都不同，所以即便本件事實涉及三家公司（我國公司、美國公司、開曼公司）的股權投資，但最高行處理起來其實跟哪一國的公司法都沒什麼關係，不需要討論依照某國公司法規定中，

²⁶ 「集團」應非法律上的概念，A 公司的簽約對象應為 B 公司，且 A 公司的營所稅是以 A 公司的個體報表作為「稅遵財」的依據，但本文認為對於被投資公司可以採用合併財務報表的「集團」來判斷經濟實質），參見註 77。

²⁷ IAS 32 第 33 段「若個體再取回其本身之權益工具，該等工具（「庫藏股」）應自權益中減除。個體本身權益工具之購買、出售、發行或註銷，均不得於損益中認列利益或損失。此種庫藏股可由個體或合併集團之其他成員取得並持有。所支付或所收取對價應直接認列於權益」。由於本文討論的是 A 公司的營所稅，故對於 B 公司（集團）有無可能適用股份基礎給付的會計處理就不加以討論。

²⁸ 比較註 38（合併）、42（作價）。本文認為民商法上的合併需要法律特別規定，若不符合法律要件才能具備合併的法律效果（不是指法人格消滅），則拆成一般交易處理，即便到了後面的稅法適用階段亦然。本件涉及外國股票，所以無涉證所稅。

²⁹ 民法學理上有認為「除雙方均為金錢以外財產補之給付，與買賣之一方為金錢以外財產權之給付，他方為金錢之給付者，有所不同外，餘則與買賣則尚無大差異」，劉春堂（2022），頁 187。

³⁰ 民法學理上有將互易以是否僅相互移轉金錢以外之財產權為標準，區分為「一般互易」與「附補足金互易」。「一般互易」係指雙方當事人均僅相互移轉金錢以外之財產權之互易，民法第三九八條所規定之互易屬之。此種互易，尚可分为下列「單純互易」與「價值互易」，前者係指「當事人互相移轉之財產權，不具有嚴格的對價之意義，亦即當事人不注重財產權之價值是否對等」，「實質上等於兩個贈與契約之併存，但因彼此互為有償，故仍非贈與，而為互易」；後者係指「當事人互相移轉之財產權，以具有同一金錢價值為前提，亦即當事人注重財產權之價值（一般係指金錢價值）是否對等」，「實質上等於兩個買賣契約之併存，而該買賣之價金，互相抵銷，但因形式上彼此並無金錢之給付，故仍非買賣，而為互易」，參見劉春堂（2022），頁 185。

股東對於公司何時有何種直接或間接的權利³¹，也沒提到營所稅的「稅務遵財務原則（下稱『稅遵財』）」³²，惟筆者認為「稅遵財」，要先依照財務會計作帳，「之後」³³再帳外調整，而非直接忽視會計帳，所以接下來將補充此部分的討論。

第二節 財務會計的處理

關於資產交換，筆者認為宜先釐清本件換入與換出的「資產」在會計³⁴上的分類。首先，會計上對於「交換」交易多所著墨者主要係 IAS 16「不動產、廠房及設備」³⁵涉及以實體資產為交換客體的情況。本件 A 公司與 B 公司所交換的資產顯非實體資產，而是財務會計上所謂的「金融工具」³⁶。本件 A 公司早在民國

³¹ 參見註 20（【寶虹換翔名案／溫達俊（綜所稅）（最高行）】）。

³² 柯格鐘（2022），頁 137；有稱為「財務會計準據主義」者，參見陳清秀（2012），頁 2-4。

³³ 查準第 2 條第 1 項「營利事業之會計事項，應參照商業會計法、商業會計處理準則、企業會計準則公報、金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則（IFRS）、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下合稱國際財務報導準則）等據實記載，產生其財務報表。至辦理所得稅結算申報時，其帳載事項與所得稅法、所得稅法施行細則、...、本準則及有關法令規定未符者，應於申報書內自行調整之」。

³⁴ 會計準則有很多套且時常變動，本文是以筆者撰寫本文時適用的國際財務報導準則之會計研究發展基金會所製作的中譯為主，參見 https://ifrs.sfb.gov.tw/ifrs/index.cfm?act=ifrs_2025_approved。

³⁵ 關於「不動產、廠房及設備」認列時之衡量，IAS 16 第 15 段「符合認列為資產之不動產、廠房及設備項目，應以其成本衡量」，而就此「（換入資產的）成本衡量」，IAS 16 第 24 段「一項或多項不動產、廠房及設備項目，可能係透過交換一項或多項非貨幣性資產，或一組貨幣性及非貨幣性資產而取得。以下討論雖僅提及一項非貨幣性資產與另一項不動產、廠房及設備間之交換，但亦適用於前述之各種交換。除(a)交換交易缺乏商業實質，或(b)換入資產及換出資產之公允價值均無法可靠衡量外，該不動產、廠房及設備項目之成本應按公允價值衡量。...。若換入項目非按公允價值衡量，其成本應以換出資產之帳面金額衡量」，第 25 段「個體決定交換交易是否具有商業實質時，應考量未來現金流量因該交易所預期改變之程度。交換交易於下列情況下具有商業實質：(a)換入資產之現金流量型態（風險、時點及金額）與換出資產之現金流量型態不同；或(b)因交換交易而使個體營運中受該項交易影響部分之個體特定價值發生改變；及(c)(a)或(b)之差異相對於所交換資產之公允價值係屬重大。為決定交換交易是否具有商業實質，個體營運中受該項交易影響部分之個體特定價值應反映稅後現金流量。該等分析結果可能顯而易見，不須執行詳細計算」，參見註 16。

³⁶ IAS 32 頁 11「本準則用語定義如下：金融工具係指某一個體產生金融資產，另一個體同時產生金融負債或權益工具之任何合約。金融資產係指下列任何資產：(a)現金；(b)另一個體之權益工具；(c)合約權利：(i)自另一個體收取現金或另一金融資產；或(ii)按潛在有利於個體之條件與另一個體交換金融資產或金融負債；或 (d) 將以或可能以個體本身權益工具交割之合約，且該合約係：(i)個體有或可能有義務收取變動數量企業本身權益工具之非衍生工具；(ii)將非以或可能非以

100 年就有「相同的投資標的、不同的股數」的相關財報揭露（參見註 98），且似未因此認列額外的損失，筆者推測一部分是因 A 公司過去將減損損失（參見註 17）做為永久性差異來處理，而非以其或最高行在本件認為的損失金額去「迴轉」過去的暫時性差異，另一部分則是涉及到投資標的同一性的問題，此涉及到 A 公司與 A 公司財報簽證會計師的判斷，筆者認為縱然當事人沒有主張，事實審法院應依職權加以調查。

關於「公司別」或法人格³⁷的主張，A 公司於原審稱其「以原持有（B 公司）股份轉換為持有（C 公司）股份之交易態樣，與公司以股份為對價進行合併³⁸之情形相當，依財政部 98 年 11 月 30 日台財稅字第 09804902120 號函（下稱財政部 98 年 11 月 30 日函）意旨，伊因係消滅公司...之股東，股利所得³⁹係以存續公司...實際入帳之收購成本（所取得淨資產價值）為準，故伊以（C 公司）損益淨額核算之每股淨值，計算轉換取得該公司股權之時價，係屬合理。被告⁴⁰卻以上開股權轉換屬投資架構轉換及股權轉換之調整，非財產交易行為，...，與最高行政法院 92 年度判字第 1099 號、第 1749 號及 96 年度判字第 1369 號等判決所涉案件中，被告對於集團內投資架構調整之股權交易⁴¹，均認產生財產交易所得，應申報納稅之見解，顯相矛盾，有違平等原則」。對此，北高行認為 C 公司與 B 公司間「雖有從屬控制關係，二者在法律上仍屬不同之權利主體，各自發行之股份均得成為財產交易之客體，是（A 公司）以原本持有之（B 公司）普通

固定金額現金或另一金融資產交換固定數量個體本身權益工具之方式交割之衍生工具。基於此目的，該個體本身權益工具不包括依第 16A 及 16B 段規定分類為權益工具之可賣回金融工具、課予個體僅於清算時交付按該個體淨資產之持分比例份額予另一方之義務之工具且依第 16C 及 16D 段規定分類為權益工具者，或該工具係於未來收取或交付個體本身權益工具之合約。」

³⁷ 參見註 46。

³⁸ 比較註 28。

³⁹ 關於損失與利得的對稱性，與 A 公司關於「股利收入」的主張不確定有無關係。稅局於原審抗辯「股份轉換之財產交易損益與日後取得之股利收入，二者之認列年度及課稅客體均不同，營利事業自應依各年度之收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後之純益額為所得額」。財政部沒有提到利益與損失應具對稱性，而是以有無變現區分「出售」、「交換」、「投票作價出資」（筆者認為屬於特種「交換」）。

⁴⁰ 稅局於原審抗辯「（A 公司）投資（B 公司）普通股 5,000,000 股，嗣以（C 公司）普通股 1 股換取（B 公司）普通股 5 股之比例，於股權轉換後持有（C 公司）公司普通股 1,000,000 股，屬（誰的？）投資架構轉換及股權轉換之調整，非財產交易行為（誰的？），且未產生實質損失」。此點為稅局復查理由提出的見解，財政部忽略，在北高行又被稅局提出。「誰的？」參見註 46。

⁴¹ 參見註 26。

股 5,000,000 股作為對價，換得（C 公司）之普通股 1,000,000 股，與查核準則第 100 條第 3 款前段所稱營利事業以他公司（即 B 公司）股票，作價抵充（對 C 公司）出資股款之情形相當⁴²，被告抗辯上開股權轉換僅屬投資架構之轉換，非財產交易行為云云，乃忽略（B 公司）及（C 公司）各為獨立之法人，（A 公司）以所持有前者之股票換取後者發行之股票，並非就其持有單一公司之股權進行調整，自非可採」。

本文認為，既然法人本身也是法律創造的概念（即便是法人實在說也是一個概念），則法人的合併也不免是一個法律創造的概念。詳言之，法人在公司法上並無所謂實質，有實質的毋寧為美國公司法上所謂的「營業（business）」。⁴³詳言之，除非「法律形式自帶實質」的命題成立，否則法人並非一個「自然概念（natural concept）」，而是由各國法律（受法律強制力保護的範圍）所定義而出的「法律上的權利義務主體」（它的意義就在於「在法律上有意義」，而在我國法律保留原則也主要是涉及人民權利義務的事項要由法律或法律授權的依據，故若一開始就不承認公司是法律上的權利義務主體，則就不會受到法律保留原則的「保護」），因此合併作為一種公司消滅（甚至是公司誕生）的「事由」也是由各國（或美國各州）法律所定義，換言之，法人的「合併」，如同「法人」一樣，是由法律所創造，亦即除非有法律規定可合併，否則「合併」並非「公司」制度邏輯上必然能推導出的結果，或是需要透過立法來提供制度使人民得以行使權利，況依舊企併法第 40 條（現為第 45 條第 1 項）於 91 年制定時的立法理由為「公司併購形成完全控股關係時，通常於業務上係整體經營，實質上為同一公司，母公司如繼續持有百分之九十股權達十二個月以上，許其選擇合併報繳營利事業所得稅，將更能符合經濟實質之課稅原則，亦可減少徵納雙方對母子公司間有無非常規交易之爭議」。本文基於 A 公司的會計處理，認為經濟實質於本件仍有討論空間，所以不認同北高行單憑有價證券是法律上不同個體所發行，就斷言是否為相同投資標的。因為營所稅是以金錢⁴³計算，所以涉及「真金白銀」的「買賣」有其特殊

⁴² 參見註 28、84；註 71（肯定說）。

⁴³ IAS 32 第 AG3 段「貨幣（現金）為金融資產，因其代表交換之媒介，故為所有交易於財務報表衡量及認列之基礎。於銀行或類似金融機構中之現金存款為金融資產，因其代表存款戶之合約權利，使存款戶可自該機構取得現金或以其餘額簽發支票或類似工具予債權人以償付金融負債」。至於貨幣性資產，IAS 21 頁 A6「貨幣性項目係指持有之貨幣單位，及收付具有固定或可決定數量之貨幣單位之資產或負債」，此用語主要用在涉及外幣兌換的情境中。

性，而「交換」更可能涉及延續性甚至是投資標的同一性的問題。以下是假設投資標的不同而繼續討論稅法上的應用。

第三節 所得稅法中的定性

第一項 損失的定義

「損失」做為日常用語與法律術語有很多意義，本文討論的是一種稱為「損失」的營所稅扣除額類型。所得稅法第 24 條第 1 項前段「營利事業所得之計算，以其本年度收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後之純益額為所得額」。從此條文觀之，稅上的損失應非與所得「對稱的（『負所得』）」⁴⁴，而是「從屬」於所得，亦即「先有所得，才有包含損失在內的各項法定⁴⁵扣除額」。

第二項 「財產交易」、「損失」、「財產交易損失」

A 公司於訴願階段提到「該損失係被投資公司（B 公司）進行組織架構重組，與（C 公司）股份轉換而取得（C 公司）之股票，因（C 公司）股票淨值低於原始投資（本文按：B 公司）成本之投資損失」、「股權淨值減少之損失」，又在北高行強調其「投資標的之公司⁴⁶既已變更，係以處分舊投資取得新投資之實質財產交易行為」，此係回應復查理由「投資架構轉換，股權轉換之調整，非（A 公司）主張財產交易之行為，此股權轉換並未產生⁴⁷實質損失」。

本文認為查準 100 條與查準 99 條的其中一個重大差異在於查準 100 條的自願性，本件的確涉及 A 公司「簽約」的行為，且看不出 B 公司可強制 A 公司簽約的跡象，此從北高行法院提到「（C 公司）係（B 公司所屬集團）因擬於臺灣證券交易所上市股票而設立，該公司設立後成為（B 公司）之控股公司，並期⁴⁸投資者配合以（C 公司）普通股 1 股換取（B 公司）普通股 5 股之比例，將原持有（B 公司）普通股轉換為（C 公司）普通股等情，為（A 公司）所自承」可知，

⁴⁴ 本文認為問題是損失的認列本來就不一定與利益等所得的加項對稱，然本件中沒人認真挑戰損失與所得或利益對稱性的問題，而是基本上都接受或迴避。

⁴⁵ 參見註 74。

⁴⁶ 參見註 37（關於法人格與投資標的之關係）。

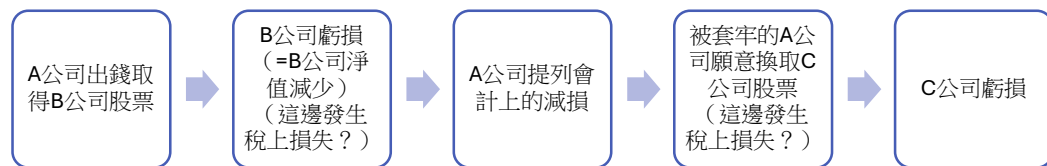
⁴⁷ 關於「產生」之措辭，參見 24。

⁴⁸ 動機論與結果論，參見註 69。

但 A 公司若「因轉換交易而蒙受損失」，與「A 公司原有的 B 公司持股之股權淨值（可能因為 B 公司持續虧損⁴⁹而）減少」是兩回事。北高行顯然混淆，方將本件爭點辨認為：A 公司主張其因將原持有 B 公司普通股 5,000,000 股，轉換為 C 公司普通股 1,000,000 股，致股權淨值減少 287,317,251 元，得依查核準則第 100 條第 3 款規定認列損失，是否有據？⁵⁰。

筆者認為 A 公司的主張似有「股權投資所取得者為被投資公司的淨值」之意，應係誤解所得稅法第 63 條之規定。詳言之，該條所規定者乃股權「估價」標準，而非股權本身的定義或描述。若是市場交易就應該是討論市價，淨值在此應該是作為一種估計的方法，如果 B 公司與 C 公司之間的淨值可以如此比較，甚至預期具有某種「延續性」反而會顯得此交易欠缺實質。

關於「不轉換即無損失？」的因果關係問題，筆者認為關鍵在於 A 公司想列報的到底是「以較高的 B 公司淨值換取較低的 C 公司淨值（假設淨值的下降是因為 B 公司虧損所致）」之交易損失，還是「A 公司持股期間，B 公司股權淨值減少」的損失？



圖：發生稅上損失的可能環節（作者自繪）

最高行雖然似乎跳脫北高行的窠臼而稱「依原判決確定之事實，系爭經濟行為既係股權資產之交換，屬前揭查核準則第 100 條第 2 款之涵攝範圍，即應探究換入資產（C 公司股票）之時價⁵¹，俾與換出資產（B 公司股票）之價值比較，如有交換損失，應予認列；如換入資產之時價無法可靠衡量時，則按換出資產之帳面價值加支付之現金，或減去收到現金，作為換入資產成本入帳，該換出資產即無交換損益」，但股權淨值的概念又從後述的「時價」層次捲土重來。

⁴⁹ 據筆者所知，B 公司與 C 公司股票皆無公開市場交易資料或向大眾公開的財務資訊，只能推測 B 公司淨值持續下降（A 公司多次提列減損，參見註 17）以至於 A 公司願意（參見註 12）交換股票，是因為 B 公司「虧損」所致。

⁵⁰ 除非北高行是以 VA「是否動稅額」而非「適用法條」為合違法的判斷標準，否則本文認為「北高行係以 VA 是否合法為訴訟標的」。

⁵¹ 綜合註 65 觀察。

第五章 關於要件「時價」

第一節 時價的意義應接近第 100 條第 1 款的售價

股東並未對被投資公司的具體資產享有控制支配權，而是享有「股東權」，所以此處的「時價」應係股東權如何估價⁵²的問題。「淨資產」不是特定資產，而是一種抽象的概念。A 公司於北高行主張作為時價，「依（C 公司）之資產淨值核算股權價值」，與所得基本稅額條例施行細則第 6 條⁵³、財政部 82 年函釋、97 年 7 月 10 日令⁵⁴、99 年 3 月 12 日令⁵⁵、101 年 5 月 24 日令⁵⁶、104 年 11 月 5 日令⁵⁷，及會計師查核簽證公司登記資本額辦法第 7 條第 2 項第 4 款規定，均相符合」。北高行認為「上述 4 令釋所稱「時價」，於標的股票為未上市、未上櫃或非屬興櫃股票之情形，係指可處分日、執行權利日或交付股票日之前一年內最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值，該日之前一年內無經會計師查核簽證之財務報告者，為依該日公司資產淨值核算之每股淨值」，規範之情形與本件有

⁵² 故也可能包含主觀控制權溢價，參見註 81。

⁵³ 北高行認為「原告稱其所受上述損失金額，係以距其取得（C 公司）股份 5 個多月前之該公司「設立時」股權淨值為計算依據，非按交易日或其實際取得股份而得以處分之日之公司資產淨值核算每股淨值予以認定，即與所得基本稅額條例施行細則第 6 條及（財政部 82 年函釋）、（104 年 11 月 5 日令）之財政部函釋就「時價」所為定義不符」。

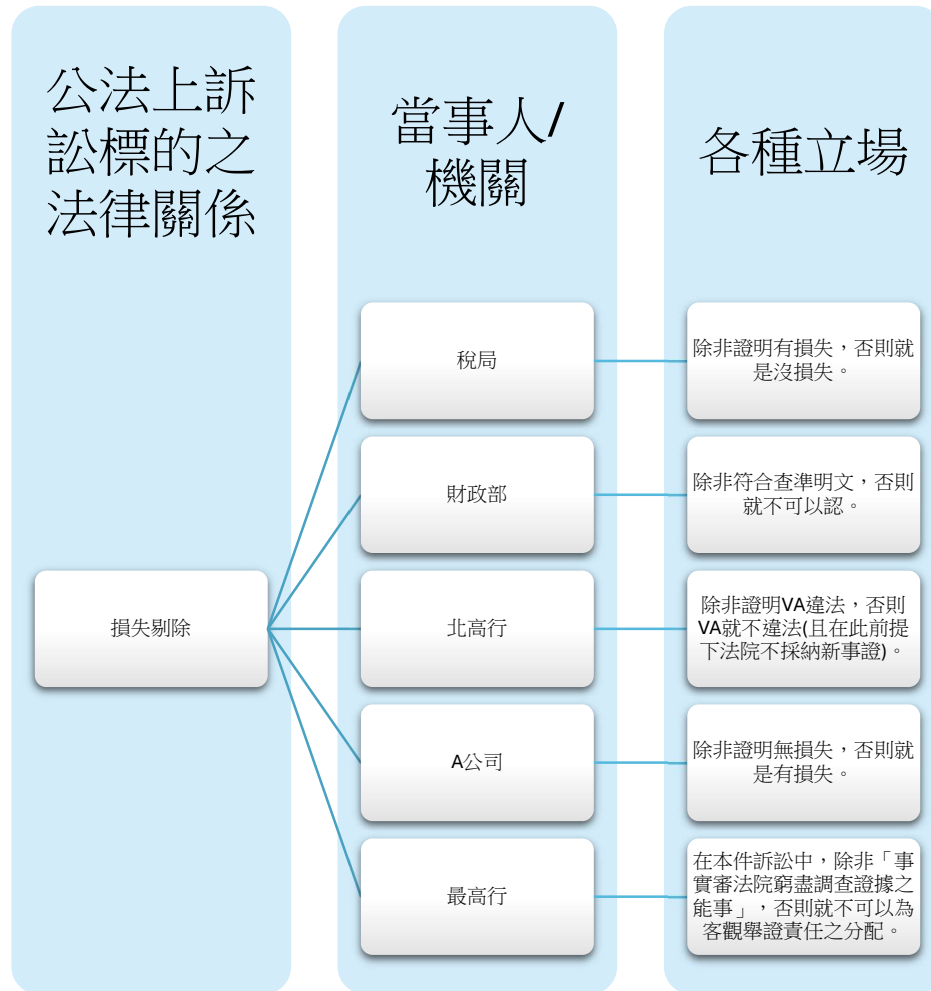
⁵⁴ 北高行認為「財政部 97 年 7 月 10 日令，則對...公司辦理現金增資發行新股依公司法第 267 條規定保留部分股份由員工認購，員工依認股計畫認購公司新發行股票者，規定可處分日標的股票之時價超過認購價格之差額部分，應計入可處分年度員工之所得額。」財政部 97 年 7 月 10 日台財稅字第 09704515241 號令。

⁵⁵ 北高行認為「財政部 99 年 3 月 12 日令，係針對公司辦理員工紅利轉增資發行股票之情形，規定...應於交付股票日按標的股票之時價計算員工薪資所得，依所得稅法第 88 條規定辦理扣繳。」99 年 3 月 12 日台財稅字第 09900025480 號令。

⁵⁶ 北高行認為「財政部 101 年 5 月 24 日令，乃就公司依證券交易法或公司法規定發行員工認股權憑證，員工依公司所定認股辦法行使認股權取得股票，執行權利日標的股票之時價超過員工認股價格之差額部分；公司依證券交易法或公司法規定，將收買之股份轉讓予員工，交付股票日標的股票之時價超過員工認股價格之差額部分；暨公司依證券交易法或公司法規定，將收買之股份轉讓予員工，依公司法第 167 條之 3 規定限制員工在一定期間內不得轉讓者，可處分日（即股票交付日）標的股票之時價超過員工認股價格之差額部分，均規定應計入執行年度或交付股票年度員工之所得額，依法課徵所得稅」。101 年 5 月 24 日台財稅字第 10100069320 號令。

⁵⁷ 北高行認為「財政部 104 年 11 月 5 日令，係就個人以勞務或信用出資取得閉鎖性股份有限公司股權，依公司章程規定於一定期間不得轉讓者，規定應以該一定期間屆滿翌日之可處分日每股時價計算股東之所得」。104 年 11 月 5 日台財稅字第 10400659120 號令。

別。由上可知，原審將計算過程當作「認事」（平等權要一模一樣，無類推適用）而非「用法」（有類推適用）。會計是「法」還是「證據」，若為後者，則最高行不可置喙。



圖：「一言以蔽之」（作者自繪）

A 公司於最高行主張「本案爭點為損失如何衡量計算⁵⁸，依查核準則第 100 條第 3 款規定，係以（C 公司）股權價值⁵⁹低於原取得（B 公司）成本部分為損失，在此計算式中，...，（A 公司）以（C 公司）淨資產價值作為衡量時價之依據，

⁵⁸ 此為「認事」還是「用法」？

⁵⁹ 最高行指出「查核準則第 100 條第 3 款之適用，僅須考量用以抵充出資股款之應收債權、他公司股票或固定資產（成本）與抵充出資股款之金額，本無庸考量被投資公司股票之時價」，原審都在吵 C 公司的時價（北高行與最高行判決書中所呈現的稅局見解，都是無從認定任何損失），有所誤解。

而（A 公司）援引所得稅及公司登記相關法令暨財政部函釋，足證「公司淨資產價值」為通案上一般對「時價」的衡量方式，即使所引法令規定或函釋規範之情形與本案損失之發生⁶⁰情形並非完全相同，（稅局）如基於實質課稅原則及行政程序法第 36 條能對（A 公司）秉持有利不利事項一律注意原則，即可參照前開法令及函釋規定認定（A 公司）系爭損失業已發生。（A 公司）業已釋明⁶¹損失計算中之單一因子（C 公司股權淨值）⁶²之衡量方式，而本案如有損失，計算損失之方式（投資成本-取得股權淨值=損失）根本無待前揭函釋，為眾所皆知之常識。原判決僅擷取片斷法令，未命（稅局）再依行政程序法第 36 條規定，在法令範圍內採認合理之時價認定方式，即以此作為否准認列系爭投資損失⁶³之理由，實有判決適用法規不當之違法」。惟所得稅法第 63 條「長期投資之握有附屬事業全部資本或過半數資本者，應以該附屬事業...按其出資額比例分配財產淨值為估價標準，在其他事業之長期投資，其出資額及未過半數者，以其成本為估價標準」。持股不到 2%，「在其他事業之長期投資」，惟若被投資公司乃公發公司卻也用淨值或成本，似不合理，遺產及贈與稅法第 10 條「（1）遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；...（2）...（3）第一項所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準；房屋以評定標準價格為準；其他財產時價之估定，本法未規定者，由財政部定之」，遺產及贈與稅法施行細則第 28、28 條之 1、29 條。

第二節 股權淨值是時價的替代而非內涵

在查準 99 案例⁶⁴中，有稱稅上採成本法，而本件卻是財上採成本法，稅上因為「以股權淨值作為時價」之故，採取比較像權益法的數值，但卻非「稅遵財」。

⁶⁰ 關於「發生」的措辭，參見註 24。

⁶¹ 參見註 91。

⁶² 而非交換時 B 公司股權淨值。每個金額都可有 A/B/C 公司在各個時間點的版本。稅局於原審抗辯「A 公司所提普通股股票價值鑑價報告，係對 C 公司股票於 102 年 3 月 31 日時之價值所為鑑價結果，非 100 年 11 月 22 日簽約時或 101 年 1 月 17 日轉換當時對雙方股票所作之鑑價報告，無法證明股權轉換基準日股票之公平價值，換股比例是否合理，亦無從據以衡量該資產所抵充出資股款金額低於成本之客觀性及準確性如何，無法核認財產交易損失」。公平價值 vs 時價。

⁶³ 定義？A 公司直到最高行還是稱為「投資損失」。

⁶⁴ 同時涉及查準 99 與所 63 的實務見解，例如【福興案（90 年度營所稅）（最高行）】。

本來以為營所稅的起手示是投資公司層次的稅遵財，結果沒怎麼看投資公司的財報，最後則是以被投資公司的財報當作證據。

本文認為行為時查準 100 條第 3 款「該資產所抵充出資股款之金額低於成本部分」不同於訴願決定中提到 A 公司復查時主張「其轉換後取得之 C 公司股權淨值低於原始投資成本，股份轉換損失實屬財產交易行為」，惟無法贊同最高行稱所得稅法 63 條的成本法就是查準 100 條第 2 款「時價」⁶⁵，因為時價應具備相類之物市場交易的因素。尤其被投資公司的股東權益是一個會計上的金額，參照框架「權益的衡量」相關條文，如第 6.87 段「權益之總帳面金額（權益總額）並非直接衡量。權益之總帳面金額等於所有已認列資產帳面金額之總額減除所有已認列負債帳面金額之總額。因一般用途財務報表並非為顯示個體之價值而設計，權益之總帳面金額通常不會等於：(a)個體權益請求權之彙總市場價值；(b)按繼續經營基礎出售整個個體可得之金額；或(c)出售個體所有資產並清償其所有負債可得之金額」，故在投資公司的層次，應回歸股權投資做為個別資產的衡量基礎。目前財務會計上的衡量基礎包含「歷史成本（第 6.4 段起）」、「現時價值（第 6.10 段起）」⁶⁶；現實價值又分為「公允價值」、「使用價值及履約價值」、「現時成本」。若接受查準 100 條 2 款的「時價」概念大致對應前述的「現時價值」概念，則由於本件的情況就是無法取得「公允價值」，則就是「其時價無法可靠衡量時」，並不會躍遷到通常連結到會計上「歷史成本」的查準 100 條 2 款「帳面價值」。

⁶⁵ 綜合註 51，最高行認為 A 公司於原審提出 C 公司）合併股東權益變動表日期與「(A 公司)以原持有 (B 公司) 股票，實際交換取得 (C 公司) 股票之時間 (101 年 1 月 17 日) 僅有十多日之差」，足夠相近，應可反映本件換入資產即 (C 公司) 股票之時價，故其時價應得可靠衡量，且認為原審應「依所得稅法第 63 條規定探究換出資產即 (B 公司) 股票之價值」做為 A 公司依查核準則第 100 條第 2 款之認列交換資產損失之基礎，是以「換入股票的淨值」去當作「換入資產的時價」，並以此去估計「換出資產的時價」，筆者則與財政部見解（參見「附錄一：查準 100 的結構」）類似，認為查準 100 條 2 項類似註 35 關於有體資產交換的邏輯，認為是以換入資產的公平價值為主。

⁶⁶ 概念框架第 6.10 段「現時價值衡量數使用為反映衡量日情況所更新之資訊，以提供資產、負債及相關收益與費損之貨幣性資訊。資產及負債之現時價值因該更新而反映現金流量估計值及其他因素（該等現時價值所反映者）自先前衡量日後之變動（見第 6.14 至 6.15 及 6.20 段）。與歷史成本不同，資產及負債之現時價值並非源自（且無任何一部分源自）產生該資產或負債之交易或其他事項之價格」。概念框架第 6.11 段「現時價值衡量基礎包括：(a)公允價值（見第 6.12 至 6.16 段）；(b)資產之使用價值及負債之履約價值（見第 6.17 至 6.20 段）；及(c)現時成本（見第 6.21 至 6.22 段）」。

第六章 稅上「損失」已否實現？

稅局於原審抗辯「上開股權轉換並無現金收付，依查核準則第 100 條第 2 項規定，應以換出資產之帳面價值（即投資成本）作為換入資產成本入帳，故無已實現之損益，被告否准認列原告所稱因股權轉換所受 287,317,251 元之損失，並無不合」，係以類似美國稅上 carryover basis 的方式，技術性的否定損失在當年度的實現，亦即損失為「零元」⁶⁷，惟本文認為營所稅上的「實現」應限於變現⁶⁸，且查準的定位是以憑證的種類定義「有名扣除額」而非查準 63 條實現門檻的具體化。A 公司一開始列報的是查準 99 投資損失，在訴訟中也有主張類似合併的效果，但不能連結到查準 99 條 2 款「合併」，因為沒有任何一家公司消滅，若說本件交易與「合併」類似，類似之處大概是在於「動機」⁶⁹還有被投資公司的「公司別」，惟筆者認為在討論查準 100 條時卻類比「合併」並不適宜，惟在北高行對於本件與合併的可比性的有無分為兩個層次中，若吾人將作價出資視為合併的一環⁷⁰，則在「是否為財產交易」的層次，北高行採肯定說⁷¹；在「證明價值」的層次，北高行認為「(B 公司)並非與 (C 公司)合併，亦未因 (C 公司)成立而消滅，(A 公司)以原持有 (B 公司)股份轉換為持有 (C 公司)股份，亦與前揭財政部 98 年 11 月 30 日函，所規範對象為公司以股份為對價進行合併者，顯有差異」，採否定說。

⁶⁷ 故非如註 72 上訴意旨所謂「既有損失就不可能是零元」。

⁶⁸ 否則就減損損失而言，在會計上早就「實現」了。惟筆者參採註 30 民法學者之見解，認為有經濟實質的交換可視為數個買賣（以金錢為對價）結合而成，故於本件仍有討論空間。

⁶⁹ 參見註 48。

⁷⁰ 參見「附錄四：與本件交易類似的商法規定情境」。公司法學者觀察合併法第 4 條第 5 款，指出「股份轉換之本質就是股東現物出資的一種。股份轉換就轉換公司之股東以其持有轉換公司的股份，對受讓公司出資而言，股份轉換含有現物出資的要素。只不過通常的現物出資，是公司 and 個別出資人的合意，故應取得各個股東之同意。而股份轉換可能是違反股東意思的強制現物出資，股份的轉換不是個別股東的意思，而是公司集體行為的效果，由公司機關代為意思表示，將個別股東持有之股份全部移轉給他公司，具有拘束全體股東之效力...，將產生企業組織結構性的變動（100%控股的型態），嚴重影響股東處分股份的權益。因此，法律除要求須經股東會特別決議外，也賦予異議股東的股份收買請求權，以為平衡」，參見劉連煜（2022），頁 193。

⁷¹ 參見註 42。

第七章 損失金額的證明

第一節 關於待證事實

在「有」經濟實質的前提下，「有無」就剩下可否承認證明區間或誤差，或者「全有全無」⁷²的問題。A 公司在北高行主張其「以取得成本為 312,800,000 元之（B 公司）股票作價，交換取得之（C 公司）公司普通股 1,000,000 股，價值僅 25,482,749 元⁷³，其間差額 287,317,251 元（即 25,482,749 元-312,800,000 元=負 287,317,251 元），得依查核準則第 100 條第 3 款規定列報損失」，北高行認為 A 公司「對其受有損失 287,317,251 元之事實，自應舉證以實其說」。

第二節 關於舉證責任的分配

北高行認為「稅務訴訟之舉證責任分配，與一般行政訴訟相同，即主張權利之人，除法律另有規定外，應就權利發生事實負舉證責任，而否認權利之人或主張相反權利之人，對權利之障礙或是消滅、抑制之事實，負舉證責任，此觀行政訴訟法第 136 條準用民事訴訟法第 277 條之規定自明。關於營利事業所得加項之收入，應由稅捐稽徵機關負舉證責任，至有關所得計算基礎之減項，即成本、費用及損失，乃權利發生後之消滅事由⁷⁴，不論從證據掌控或利益歸屬之觀點，均應由主張扣抵之納稅義務人負擔證明⁷⁵責任」，北高行似乎看的是 VA 是否違法

⁷² 最高行判決書所載 A 公司上訴意旨中提到「原判決既肯認系爭交易屬查核準則第 100 條第 3 款之出售或交換資產損失，接下來待證事實僅為損失金額之多寡，在損失存在前提下，系爭損失絕不可能為零（若損失為零則表示損失不存在，與前提矛盾）。就損失金額衡量之爭執，原判決縱認上訴人對系爭損失計算有關（C 公司）股權價值之衡量時點未精確至取得股票日期 101 年 1 月 17 日，其影響亦應為損失金額多寡之問題，但絕不會完全沒有發生損失（即損失不存在），原判決否准認列系爭損失，顯與原判決肯認損失存在前提矛盾」，但本文認為納稅人有協力義務。關於「發生」，參見註 24。

⁷³ 此為 A 公司於原審起訴狀所列「股份交換損失計算表」所謂「交易日（C 公司）公司股權淨值 1,863,900,000 元」（但 A 公司後於準備程序中陳述此實為 C 公司於 100 年 8 月 10 日設立時，股本加資本公積之總和），除以「（C 公司）公司發行股數 73,143,600 股（即普通股股本 731,436,000 元/面額 10 元）」，得出「交易日（C 公司）每股淨值為 25.482749」，再乘以（A 公司）持有之（C 公司）股數 1,000,000 股之乘積。假設 B 公司是 C 公司創立時的唯一股東，則此金額是 B 公司對於 C 公司的「出資」，應該沒有循環計算，假設 C 公司沒有增減資，股票一次於設立時發行給 B 公司，B 公司再分別移轉給包含 A 公司在內的 B 公司原有股東或其他人。

⁷⁴ 套用到營所稅上的淨值課稅的另種詮釋：扣除額本身是納稅人主張的權利，參見註 45。

⁷⁵ 本文認為應探究此指 A 公司對稅局證明還是對法院證明，參見註 25。

的證據，稅表對應查準，若人民的營所稅納稅義務之履行係以依照稅表申報格式申報為必要，而稅表依照查準設計，則查準就會實質上影響到人民的權利與義務。換言之，查準不能直接賦予人民權利，但會讓 VA 很難被打掉，因為行政命令不拘束法院，但若法院只能審 VA 合法性，只要個案中的稅局是依照查準「依法行政」，所以只要不是稅局「對於鐵證視而不見」，則稅局剔除都沒有違法。民事訴訟法 277 條是以請求權為基礎，但行政訴訟法似無法對應民法訴訟標的權利或事實單位型。人民要依照查準的形式（項目別 vs 金額；嚴格證明），並且實質「證明」（自由證明）事實到稅局滿意的程度，否則就要向法院證明行政處分違法，而法院又極度限縮行政處分被認定為違法的空間，對於納稅人恐過於嚴苛。

最高行援引行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條、第 134 條規定，稱「我國行政訴訟法於撤銷訴訟，及於其他訴訟，遇到與公益有關之事項，係採職權探知（調查）主義，當事人（包括被告機關）並無主觀舉證責任（向法院提出證據之行為責任），然職權調查證據有其限度，仍不免有要件事實不明的情形，由於法院不能拒絕審判，最後必須做出決定，而分配其不利益之歸屬，因此尚有客觀之舉證責任。故在職權探知主義下，事實審⁷⁶法院必須窮盡調查證據之能事（行使闡明權令兩造聲明證據或自行依職權調查），最後仍無法對要件事實的存在獲得確信的心證，始得為客觀舉證責任之分配，如果尚有調查證據之可能，卻逕為客觀舉證責任之分配，即屬率斷」。

第三節 關於「證明度」與「精確度」

關於（A 公司）的第一種舉證方法，北高行認為（A 公司）與 B 公司所屬集團⁷⁷係於 100 年 11 月 22 日簽訂股份轉讓協議書，且於 101 年 1 月 17 日實際交換取得⁷⁸C 公司股票之時，已距 C 公司設立之 100 年 8 月 10 日逾 5 個月，A 公司仍以 C 公司設立日之股權淨值 1,863,900,000 元作為計算 A 公司取得 C 公司股票當時之真實價值，自值存疑。

⁷⁶ 最高行政法院為法律審。

⁷⁷ 參見註 26。

⁷⁸ 北高行判決書第 160 行起提「原告持有之 VSC-Cayman 公司股票上記載日期」，故應為紙本。

關於原告的第二種舉證方法，亦即以一份鑑價報告⁷⁹試圖證明 C 公司股票於 102 年 3 月 31 日每股淨值為美金 0.73 元，以此換算伊轉換後取得之該公司普通股 1,000,000 股之淨值，於 102 年 3 月 31 日僅餘 21,900,000 元，足見 C 公司股票價值係持續減損⁸⁰，北高行認為該鑑價報告僅就 C 公司股票於 102 年 3 月 31 日之價值予以分析評價，無從得知 C 公司股票價格是否如 A 公司所主張，自 101 年 1 月 17 日取得 1,000,000 股⁸¹普通股後至 102 年 3 月 31 日之期間內呈現下跌走勢⁸²，更不足以推知 A 公司於 101 年 1 月 17 日以 B 公司股票交換取得之 C 公司股票價值為何；北高行並稱 A 公司並未成功證明「其主張以①⁸³取得成本為 312,800,000 元之（B 公司）股票作價⁸⁴，換得之（C 公司）股份②⁸⁵價值僅 25,482,749 元，③⁸⁶致其因而產生損失 287,317,251 元一節，係屬真實」。

關於使用淨值（股東權益），北高行認為會計師查核簽證公司登記資本額辦法第 7 條第 2 項第 4 款規定：「.....會計師受託查核簽證前項資本額登記，應行查核事項如下：.....四、**股票抵繳股款者**：應查核其估價是否依下列規定辦理：（一）未上市、未上櫃、未興櫃之公司股票，得以衡量日該公司之資產淨值估定之。.....」可知會計師受託查核簽證公司設立登記或合併、分割、收購、股份轉

⁷⁹ 為何要用鑑價報告證明財報應該就可以證明的 C 公司淨值？北高行判決書中提到 A 公司做為證物的 C 公司「普通股股票價值」鑑價報告內容已表明該報告有「援引作為比較基礎之 Lexmark International Inc.、Netgear Inc.、Planar System Inc.、Video Display Corporation、Wells-Gardner Electronics Corp.、ASUSTeK Computer Inc.及 Acer Inc.等公司股價，亦係該等公司股票於 102 年 3 月 31 日之價值」。

⁸⁰ 參見註 19。

⁸¹ 假設本件持股比例不到 2%不算高，所以不考慮控制權溢價。

⁸² 「北高行判決書中提到 A 公司主張其計算第 100 條第 3 款損失的方式為「依 VSC-Cayman 公司設立時之股東權益按伊持股比例計算，伊於轉換後取得之 VSC-Cayman 公司股權淨值為 25,482,749 元，與原始投資成本 312,800,000 元相較，減少 287,317,251 元」，「再參諸伊提示之 VSC-Cayman 公司普通股股票價值獨立專家鑑價報告顯示，該公司股票於 102 年 3 月 31 日每股淨值為美金 0.73 元，以此換算伊轉換後取得之該公司普通股 1,000,000 股之淨值，於 102 年 3 月 31 日僅餘 21,900,000 元，顯示 VSC-Cayman 公司股票價值持續減損」。本文認為光憑兩個樣本的確不能建立「走勢」。財務會計雖有使用區間估計（參見註 89）來得出數字，但與營所稅就是要計算收多少「錢」不同。另參見註 87。

⁸³ 幾乎無爭執。

⁸⁴ 似乎不算是作價（參見註 42），因為交易相對人是 B 公司而非 C 公司。

⁸⁵ 本件當事人間、各級行政機關、各級法院之間的主要爭執點。

⁸⁶ 本文認為此為主要爭點。

換、增加實收資本額變更登記時，對於股東以未上市、未上櫃、未興櫃之他公司股票抵繳股款者，其價格之查核，係以該他公司股票於衡量日（即基準日前 2 個月內）資產淨值估定之價格為據，此觀同款第（二）、（三）目對於以興櫃公司及上市、上櫃公司股票抵繳股款者，規定係以該等股票衡量日之平均成交價及收盤價估定之，即可明瞭。惟原告主張其因以 B 公司之股份作價抵充對 C 公司之出資股款致受有損失，並非以作為抵充標的之 B 公司之資產淨值作為計算標準，而係以嗣後交換取得之 C 公司股權淨值為據，故與前引會計師查核簽證公司登記資本額辦法第 7 條第 2 項第 4 款，對於用以抵繳股款之股票價值所定查核方式，有所出入，原告稱其計算上述股權交換損失之標準，...，仍難採憑。查核資本額辦法是針對「被作價入股的公司」而設，而非站在「作價入股的股東」的立場，除非用損益對稱連結。

最高行則認為「原審徒以（A 公司）所提證據，無法證明其主張以取得成本為 312,800,000 元之（B 公司）股票作價，換得之（C 公司）股份價值僅 25,482,749 元，致其因而產生損失 287,317,251 元一節，係屬真實等語為由，而為上訴人敗訴之判決，似認上訴人就其主張有向法院提出證據之行為責任（主觀舉證責任），已有未洽」，從北高行判決理由對於 C 公司 100 年底財報的忽視，似可推知「除非 A 公司證明『真實』，否則判決結果會與「A 公司主張的事實被證明『不真實』」相同，而加諸於 A 公司的「真實性」概念似乎悄悄替換成「（數值的）精確性」概念，或者中間可能有正負無限大的無限多種變化⁸⁷，所以可能根本沒有損失的「證明度（反過來說就是『懷疑度』）」概念。

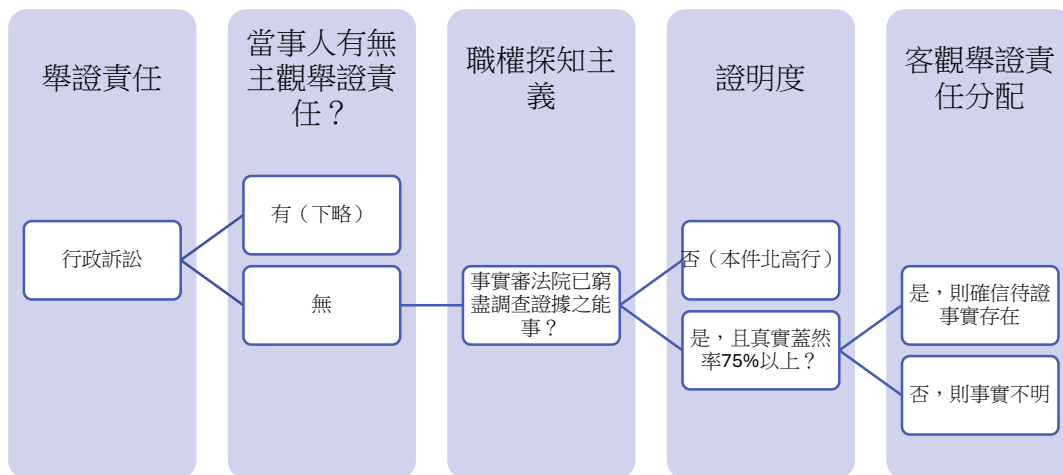
最高行稱「法院應將待證事實調查或闡明至何種程度，始能使其心證達到認為真實的確信，則屬證明度的問題，基於行政訴訟對人民權利保障及行政合法性控制的作用，...，故行政訴訟所要求的證明程度應是高度蓋然性，只要其真實蓋然率達百分之七十五以上，即得確信待證事實存在，達不到此證明度，始屬事實不明」。

A 公司於最高行主張「就本案待證事實—換得（C 公司）股權價值，上訴人已就（C 公司）股權價值釋明⁸⁸計算方式及依據，並提具相關財務資料佐證。原判決縱對上訴人採用 100 年 8 月 10 日淨值計算時隔 5 個月後 101 年 1 月 17 日換得股票之價值有所疑慮，然就上訴人於起訴狀證物 7 提示之（C 公司）合併股東

⁸⁷ 參見註 82

⁸⁸ 參見註 91。

權益變動表亦載有 100 年 12 月 31 日股權淨值金額，此日期與 101 年 1 月 17 日僅有十多日之差，若係採此一日期計算淨值為 1,933,963,000 元(=1,956,647,000 元-少數股權 22,684,000 元)，此淨值僅與 100 年 8 月 10 日淨值 1,863,900,000 元差異 70,063,000 元，尚不及 4%。上訴人所提出之證據實已盡可能地接近事實，原判決應依職權調查證據以盡可能接近事實做為裁判基礎，然原判決忽略採更接近取得股票日期之股權淨值作為計算系爭損失之可能，未就此證據進行調查，並將心證之理由載明於判決，實有判決不備理由之違法。...且就上訴人於原審法院提供之相關事證觀之，在損失接近 0 與 287,317,251 元兩端間明顯偏向損失為 287,317,251 元端⁸⁹，原判決形成心證似與證據相悖，實應有依職權調查之必要⁹⁰，原判決僅因股權價值衡量日期此等些微差異逕自否認全部損失，原判決對上訴人舉證程度要求實違比例法則」。



圖：最高行對於本件舉證責任之見解（作者自繪）⁹¹

⁸⁹ 區間，參見註 82。

⁹⁰ 北高行未依職權調查。

⁹¹ 關於證明度，是否進一步區分「自由證明方法的釋明（參見註 61、88）」及「客觀舉證責任的分配準用民訴 277」？

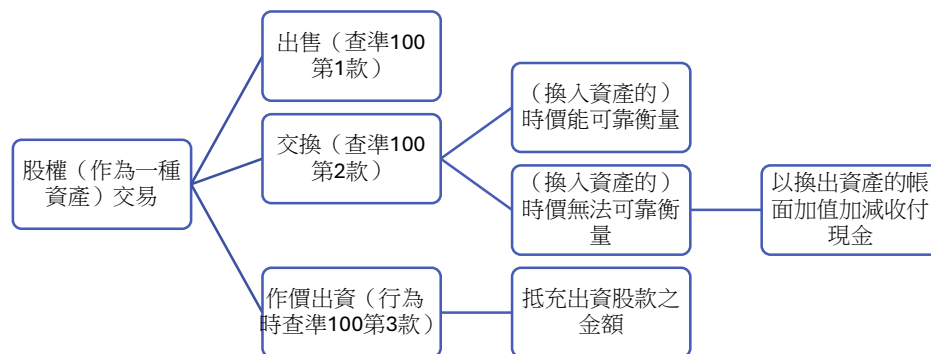
第八章 結論

根據本文的幾個切入點，「股權淨值」、「交換」、「損失」、「時價」摘要如下。首先，本文認為既然營所稅的繳納限於金錢，則租稅客體應係「金錢」而非實物或非金錢的權利本身，所以所謂的「估價」就是在決定稅基而非估計稅基。「時價」應具有市場意涵，並非系爭標之物之實際售價，而是當時相類之物的行情，絕對不可能如本件最高行的法律適用，將查準 100 條之時價直接對應到某間公司的「股權淨值」，尤其是本件股東所換出或換入的嚴格來講是「有價證券」，退一步講是「股東權」，「股權淨值」只是「股東權」的一種估計，還會受到一次出售多少持股（相對於其他股東的持股）等主觀因素影響。本件納稅義務人 A 公司涉及的是「交換」交易，因為本件沒人認為 A 公司能影響 B 公司是要組織重組還是其他目的無關，先不論筆者的疑問是在於 A 公司可否選擇不交換，至少不能如稅局主張，「B 公司要組織重組」等於「做為小股東的 A 公司所面臨的沒有經濟實質」，毋寧是要問：我國是否對此有區分所得（或損失，假設採「損益對稱論」）的發生與實現的時點的特別規定。關於損失，本文認為稅上損失與財上損失應該概念相近，所以是「稅遵財」的主要適用時機，惟筆者觀察 A 公司 100 年度財報，目前的理解是 A 公司並未在財上認列「損失」，只是希望在 101 年的稅上某種程度「實現」之前多次提列的減損損失，所以並不是因為財上實現處分損失，進而依循稅遵財主張在稅上認列，而且不符合目前所得稅法或查準的特別實現門檻（本文認為查準 99 與 100 條是關於損失實現的特別規定），依查準 100 條 2 款「時價無法可靠衡量」（除非 A 公司應該補提的證據是 C 公司盡量靠近交換日的「市價」鑑價報告，若無法提出則不能認列），稅局剔除為有理由。

第九章 參考文獻及裁判書簡稱

- 1 六劃：安侯建業，公司間換股合作之法律及稅務議題，安侯建業通訊，2022 年 2 月號，
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/tw/pdf/2022/02/tw-tax-news-update-and-tcr-202202.pdf.coredownload.inline.pdf>。
- 2 九劃：
 - 2.1 柯格鐘，稅捐法秩序—稅捐、稅法與基本原則，2023 年。
 - 2.2 陳清秀，稅務會計與財務會計之區別，東吳公法論叢，5 期，頁 403-430，2012 年。
- 3 十五劃：
 - 3.1 劉連煜，現代公司法，17 版，2022 年。
 - 3.2 劉春堂，民法債編各論（上），2 版，2022 年
- 4 裁判書
 - 4.1 【寶虹換翔名案／溫達俊（綜所稅）（最高行）】最高行政法院 111 年度上字第 866 號判決
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPAA,111%2c%e4%b8%8a%2c866%2c20240111%2c1>
 - 4.2 【新光合成纖維案（北高行）（99 年度股東可扣抵稅額）】臺北高等行政法院 105 年度訴字第 1324 號判決
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPBA,105%2c%e8%a8%b4%2c1324%2c20180201%2c1>
 - 4.3 【福興案（90 年度營所稅）（最高行）】最高行政法院 98 年度判字第 1524 號判決
<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPAA,98%2c%e5%88%a4%2c1524%2c20091231%2c1>

附錄一：查準 100 的結構



圖：訴願決定對於行為時查準 100 的理解（作者自繪）

第一節 查準 100 I

查準 100 第 1 款「一、資產之未折減餘額大於出售價格者，其差額得列為出售資產損失。」

第二節 查準 100 II

查準 100 第 2 款「二、資產之交換，應以時價入帳，如有交換損失，應予認列。其時價無法可靠衡量時，按換出資產之帳面價值加支付之現金，或減去收到現金，作為換入資產成本入帳。」

第三節 行為時查準 100 III（現為 IV）

現行查準 100「三、營利事業處分依營利事業認列受控外國企業所得適用辦法規定認列投資收益之受控外國企業股份或資本額，其處分損失之計算，應依該辦法規定辦理。四、營利事業以應收債權、他公司股票或固定資產等作價抵充出資股款者，該資產所抵充出資股款⁹²之金額低於成本部分，得列為損失⁹³；其自中華民國九十三年一月一日起，以技術等無形資產作價抵充出資股款者，亦同。」

⁹² 查準 99 減資彌補虧損以面額為準。

⁹³ 代表承認是新資產。

附錄二：A 公司個體年報揭露之「VIEWSONIC CORPORATION」持股⁹⁴

年度	頁碼	帳列科目	股數(仟股)	帳面金額 (仟元)	持 股 比 例	公允價值 (仟元)
90 年	45	長期投資	5,000	312,800	1.4%	未揭露
91 年	54		5,000	312,800	1.41%	未揭露
92 年	39		8,000	312,800	2.20%	未揭露
93 年	74		8,000	312,800	2.20%	未揭露
94 年	76		8,000	262,800 ⁹⁵	2.20%	未揭露
95 年	59		8,000	262,800	2.20%	未揭露
96 年	53	以成本衡量之金融 資產-非流動	8,000	262,800	2.20%	未揭露
97 年	54		5,000	200,000 ⁹⁶	1.42%	未揭露
98 年	54		5,000	150,000 ⁹⁷	1.42%	未揭露
99 年	51		5,000	150,000	1.36%	未揭露
100 年			1,000 ⁹⁸	150,000	1.36%	未揭露
101 年			1,000	100,000 ⁹⁹	1.33%	未揭露
102 年		透過損益按公允 價值衡量之金融 資產-流動 ¹⁰⁰	1,000	100,000	1.33% ¹⁰¹	107,614 ¹⁰²

⁹⁴ 舊版「公開資訊觀測站」可查得之 A 公司個體財報資訊最早可追溯到民國 90 年。

⁹⁵ 筆者從財報上看不出有對此提列減損。

⁹⁶ 個體財報頁 20「八、財務報表附註」、「(四)重要會計科目之說明」項下「(五)以成本衡量之金融資產-非流動」提到 A 公司「於民國 97 年度...，針對持有之有價證券評估其價值有下跌之虞，提列減損損失...\$62,800（本文按：仟元）」，應係指對 Viewsonic 持股所提列者。

⁹⁷ 個體財報頁 21「八、財務報表附註」、「(四)重要會計科目之說明」項下「(五)以成本衡量之金融資產-非流動」提到 A 公司「於民國 98 年度...，針對持有之有價證券評估，因可回收金額低於帳面價值，提列減損損失...\$50,000（本文按：仟元）」，應係指對 Viewsonic 持股所提列者。

⁹⁸ 參見註 20。

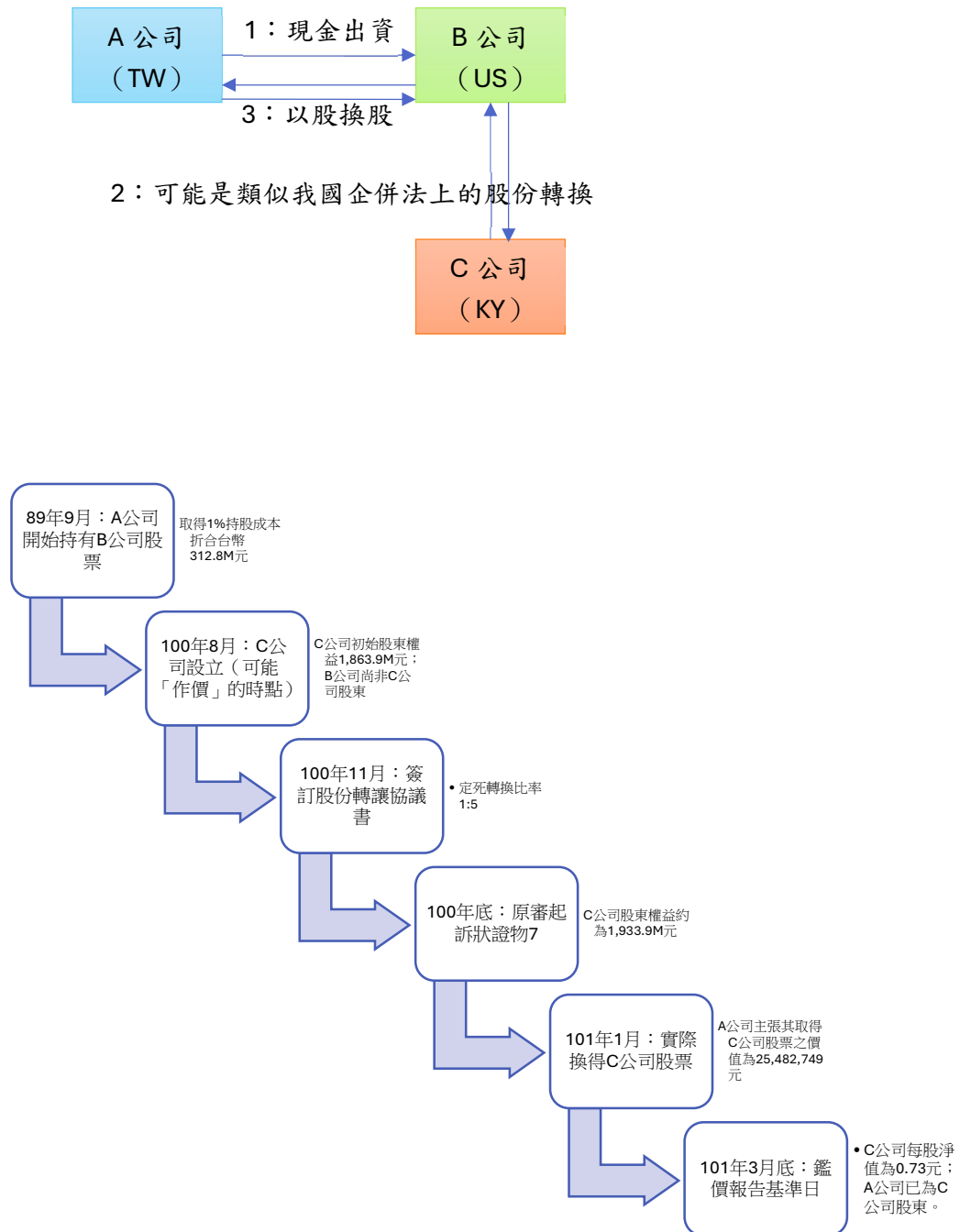
⁹⁹ 個體財報第 20 頁「六、重要會計科目之說明」、「(四)重要會計科目之說明」項下「(五)以成本衡量之金融資產-非流動」第 2 點提到 A 公司「於民國 101 年度，針對持有之有價證券評估，因可回收金額低於帳面價值，而提列減損損失計\$50,000（本文按：仟元）」，應係指對 Viewsonic 持股所提列者。

¹⁰⁰ 關於會計科目名稱的變動，第一次是因為...，第二次是因為該公司於當年首次採用 IFRSs。

¹⁰¹ 參見 102 年第 1 季合併財報頁 71。

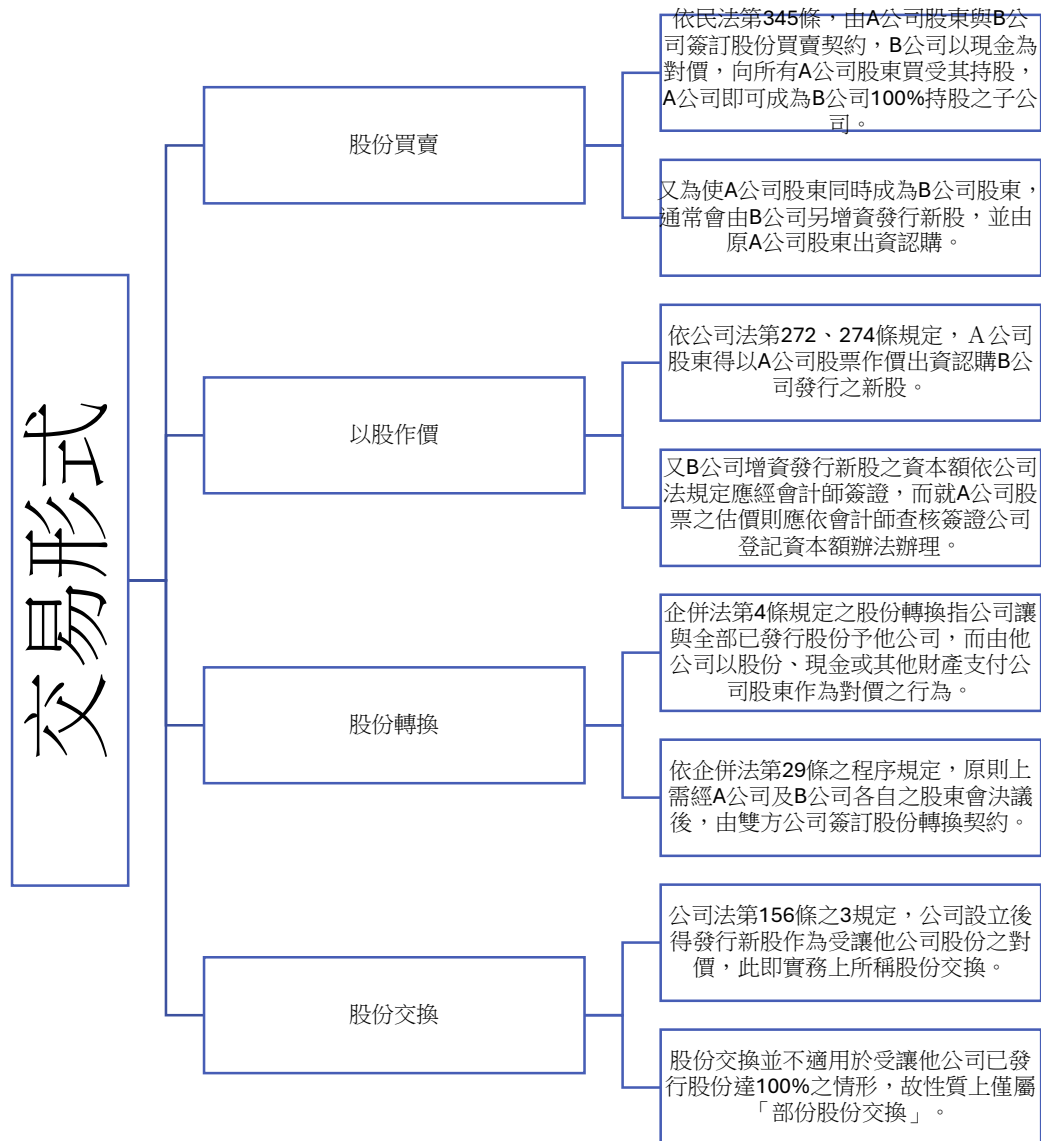
¹⁰² 102 年度合併財報與個體財報均同此數字，應意味著應無 A 公司以外的合併個體持有 B 公司或 C 公司股票，所以尚不清楚為何 102 年第 1 季合併財報所載「市價」為 59,183 仟元，與本件判決書所呈現之相同截止時點的鑑價報告所載 21,900 仟元會相差兩倍以上的原因。

附錄三：關係圖、時間軸及各種金額¹⁰³



¹⁰³ 筆者自行繪製。

附錄四：與本件交易類似的商法規定情境¹⁰⁴



¹⁰⁴ 筆者參考 KPMG（2022）繪製。